

1502424-47.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... o local já ser conhecido como ponto de tráfico, a tentativa de fuga do réu, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade senão fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1502424-47.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502424-47.2021.8.26.0537

2021/001768

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE OLIVEIRA SENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

GABRIEL DE OLIVEIRA SENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 18:00 horas, na Travessa Novo Horizonte, altura do n.º 22, Bairro Jardim Canhema, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão de juiz de plantão (fls. 41/44).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 100/101), sendo recebida a denúncia em 22.02.22 (fls. 104/105). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de março de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21, n.º 2646/22 e n.º 2650/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O

réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, afastando-se a redução do art. 33, §4.º por ter atos infracionais, fixação de regime fechado.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de condenação que seja considerada a sua menoridade, a redução do art. 33, §4.º, a fixação do regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 09), o réu permaneceu calado. Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que estava jogando bilhar, sinuca, no bar há uns 20 minutos com o dono deste (Tião). Os policiais chegaram, colocaram todos para fora do bar e o levaram para perto do carro, onde acharam as drogas (havia uma pilha de lixo, um papelão e drogas embaixo). Trabalhava fazendo "bicos" em oficina mecânica. Nunca foi processado. Tem 20 anos. Narrou que já foi usuário de drogas, mas tinha parado. Teve passagem quando menor.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que realizavam operação de combate ao tráfico e que ao ingressarem na Travessa Novo Horizonte, Bairro Canhema, avistaram o réu e outros dois homens em atitude suspeita, detrás de um veículo (placa não anotada) estacionado. Relataram que o réu e os dois homens demonstraram inquietude e nervosismo ante a presença da viatura, e que estes correram para vielas próximas, enquanto o primeiro entrou em um bar. Narraram que foram até este bar e abordaram o réu, o qual confessou que estava vendendo drogas no local e informou que as guardava embaixo de alguns papelões que estavam ao lado da roda dianteira de um veículo estacionado. Informaram que foram até o local indicado pelo réu e localizaram 62 tabletes de maconha, 84 invólucros de cocaína e 91 pedras "crack", acondicionados em duas sacolas plásticas.

Vítor (policial), em juízo, narrou que fazem uma operação de combate a crimes, viram o réu na posse dos entorpecente (pegando drogas na sacola para entregar para usuário) e mais dois homens mais afastados. O réu se evadiu para o bar. Afirmou que abordaram o réu no bar. Informou que o réu confessou que vendia e indicou onde estavam as drogas (junto do local que o avistaram), perto de um carro. As drogas estavam divididas em porções, prontas para a venda. Informou que não era uma quantidade para uso. Não conhecia o réu anteriormente. Disse que viu o réu mexendo na sacola com drogas, pessoas a certa distância (uns 5 metros) e depois entraram no bar. Acredita que havia dinheiro, não se recordando a quantidade.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Edson. Narrou que viu o réu abaixando e mexendo na sacola com drogas e depois entrou no bar. Confirmou que o réu confessou e indicou aonde estavam as drogas, local que as apreenderam. Não lembra se havia dinheiro. Dois correram para a viela e o réu entrou no bar.

O fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade e variedade de drogas apreendidas (fls. 17 - 62 porções de maconha, 84 porções de cocaína e 91 invólucros de "crack"), divididas em porções, o fato de o local já ser conhecido como ponto de tráfico, a tentativa de fuga do réu, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade senão fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, trazer consigo e guardar.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que viram o réu mexendo nas drogas, que o abordaram no bar, o mesmo confessou e indicou o local onde as guardava, onde foram apreendidas.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, trazer consigo, ter em depósito e guardar. A negativa judicial do réu está isolada, posto que alegou que estava jogando sinuca no bar, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos policiais.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (62 porções de maconha, 84 porções de cocaína e 91 invólucros de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 22/24) e laudo definitivo (fls. 150/152).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 159/162).

Inobstante o réu tenha respondido por atos infracionais (fls. 31/32), os fatos praticados antes dos 18 anos não podem ser considerados em seu desfavor, já que conforme F.A de fls. 159/162, é primário e não ostenta antecedentes criminais (STJ, 5ª Turma, HC 289.098/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/05/2014, HC 249015/SP, HC 81866/DF).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 17 - 62 porções de maconha, 84 porções de cocaína e 91 invólucros de "crack") já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e é menor de 21 anos, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO GABRIEL DE OLIVEIRA SENA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto às duas sacolas plástica apreendidas (fls. 17), já periciadas (fls. 153/154), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 45) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 09 março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA